

1501257-93.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... o modo como estava praticando o tráfico o denunciado; que, durante esta campana constatamos que o individuo com as característica descritas estava praticando o tráfico, e chegamos a filmar transação de venda, fornecendo as características para a equipe de abordagem; que foi na Equipe de abordagem Dr Eduardo, e os Investigadores Sérgio e Brizano em viatura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1501257-93.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501257-93.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN HENRIQUE FERREIRA AGUIAR

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ALAN HENRIQUE FERREIRA AGUIAR, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 11 de novembro de 2021, por volta de 16h15min, na rua Cecílio Nicolau, nº 90, Bairro Porto Belo, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, nas imediações de estabelecimentos de ensino e de saúde, tinha em depósito 24 porções de "cocaína" com peso bruto de 40,0 gramas e 14 porções de "maconha" com peso bruto 180,0 gramas, sendo registrado em vídeo vendendo os entorpecentes para um indivíduo que se aproximou.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "na data dos fatos policiais civis se dirigiram ao local acima mencionado para verificar a procedência de informação recebida apontando que um indivíduo trajando bermuda, blusa de cor cinza e boné ali estaria realizando o tráfico de entorpecentes. Os agentes públicos então, em viatura descaracterizada, efetuaram campana no local e constataram que o denunciado estava de fato realizando a traficância, tendo sido registrado em vídeo ele vendendo os entorpecentes para um indivíduo que se aproximou, conforme se verifica nos prints às fls. 49/57 e vídeo com link à fl. 1191. Além disso, os policiais civis também registraram nas mencionadas imagens que, como de praxe no

chamado tráfico de rua, o denunciado mantinha a droga escondida próximo ao local da venda, a saber, em meio à vegetação e partes quebradas na calçada (cf. imagem à fl. 40). Assim, constatada a prática criminosa, os agentes públicos acionaram outra equipe policial que estava no apoio para realizar a abordagem do denunciado, sendo que em poder dele foi apreendida a quantia de R\$ 44,00 em moeda corrente fracionada, produto da mercancia ilícita. Na sequência, os policiais foram até o local onde o denunciado escondia as drogas, no que apreenderam as 24 porções de "cocaína" com peso bruto de 40,0 gramas e as 14 porções de "maconha" com peso bruto de 180,0 gramas. Formalmente interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a prática delitiva, alegando ser usuário de "crack" e que praticava a traficância para sustentar o seu vício (fl. 04). Assim, as circunstâncias apuradas pela polícia civil com imagens de ALAN na prática da traficância e manuseando as drogas no local em que foram encontradas, o local da prisão, conhecido ponto de venda de drogas, a quantidade de entorpecentes, a forma de disposição fracionada e embalada para a venda, a quantia em dinheiro e a confissão do denunciado demonstram, com segurança, que ele tinha em depósito os entorpecentes com a finalidade de tráfico. Apurou-se, ainda, que o denunciado praticou a traficância nas imediações dos estabelecimentos de ensino EMEF Ruth Barroso Teixeira e Creche Prof. Silvia Melo Marques Ribeiro e da unidade de saúde UBS Antônio Gallo, todos num raio inferior a 400 metros, conforme relatório de investigação e croqui de fls. 124/126."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

De início aponto a licitude do meio de obtenção de prova.

A acusação está calcada em busca pessoal realizada por policial civil.

Havia justa causa para tal.

A busca pessoal sem mandado judicial, por restringir o direito à liberdade de locomoção e também a intimidade (incisos X e XV do art. 5º da Constituição), somente pode ser feita quando diante de fundada suspeita de que a pessoa alvo esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso, embora a denúncia anônima não seja por si só aceita como justa causa para a diligência invasiva, o procedimento foi precedido de investigação prévia, ainda que breve e informal (justificado pela atualidade da denúncia anônima), devidamente filmada, permitindo-se à defesa amplas possibilidades de exercer o contraditório e combater a licitude do ato (sindicabilidade da alegação).

A campana, de fato, evidenciou uma movimentação que tornava provável que a pessoa alvo estivesse na posse de drogas, as quais constituem corpo de delito da infração prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 (§§1º a 5º do art. 50).

Nestas circunstâncias, a abordagem policial com busca pessoal não só era legítima, como também necessária para o cumprimento do dever que é imposto à corporação pelo art. 144 da Constituição (em especial o §4º que dá à Polícia Civil a incumbência de apurar infrações penais).

Quanto ao mérito, anoto que o topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar

o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico (finalidade da proteção penal) é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 33/36), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 38), pelos laudos periciais (fls. 201/203) que resultaram positivo para as drogas encontradas, pelas filmagens (fls. 119) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o policial civil Brizano Aparecido da Silva na fase policial, disse que "nesta data estava de serviço quando receberam informações que um indivíduo com bermuda, blusa cinza e boné estava praticando a traficância em conhecido ponto de venda de drogas no Bairro Porto Belo; que, os Policiais Cíveis Carlos e Stringhetta foram em uma viatura descaracterizada a fim de averiguarem o fato, e obtenção de elementos probatórios de venda de drogas; que, durante esta campanha, estes constataram o indivíduo na mercância de drogas e chegaram a filmar transação de venda, fornecendo as características para a equipe de abordagem; que foi na Equipe de abordagem o depoente em viatura descaracterizada juntamente com este signatário e o Investigador Sérgio; que, ao chegarmos no local o depoente e este signatário desceram rapidamente da viatura e efetuaram a abordagem do indivíduo identificado como ALAN HENRIQUE FERREIRA AGUIAR; que, efetuada revista no mesmo encontrada no bolso de sua bermuda a quantia de RS44,00 em moeda corrente fracionada; que, Carlos e Stringhetta foram até o local onde o indivíduo estava guardando o entorpecente e vieram a encontrar 24 eppendorfs de Cocaina e 14 porções de Maconha, fracionados, prontos para serem comercializados; que, o depoente não conhecia o indiciado." Em juízo manteve sua versão. Aquele ponto de tráfico está entre o primeiro e o segundo ponto mais movimentado da cidade. A avenida ali é bem movimentada; o movimento ali é voltado para venda de droga. Há creches e escolas próximas. A creche dista poucos metros da biqueira. Há uma UBS próxima da creche. A escola dista uma rua. Pessoas fazem outro trajeto para não expor as pessoas à biqueira. Todos estes equipamentos públicos citados funcionam no horário próximo da ocorrência. Trata-se de um ponto conhecido de venda de drogas. Com viatura caracterizada não conseguem fazer abordagem por conta dos "olheiros" e pela rota de fuga pelo mandiocal. Polícia Militar faz patrulhamento ostensivo no local. A pessoa imputada não esperava pela abordagem e não esboçou reação. Não percebeu alteração de ânimo ou psicomotora da pessoa imputada. Não conhecia a pessoa imputada.

A testemunha de acusação, o policial civil Carlos Henrique Campos, na fase policial, disse que "nesta data estava de serviço quando receberam informações que um indivíduo com bermuda, blusa cinza e bone estava praticando a traficância em conhecido ponto de venda de drogas no Bairro Porto Belo; que, o depoente e Stringhetta foram em uma viatura descaracterizada a fim de averiguarem o fato, e obterem o modo como estava praticando o tráfico o denunciado; que, durante esta campanha constatamos que o indivíduo com as característica descritas estava praticando o tráfico, e chegamos a filmar transação de venda, fornecendo as características para a equipe de abordagem; que foi na Equipe de abordagem Dr Eduardo, e os Investigadores Sérgio e Brizano em viatura descaracterizada; que, ao chegarem no local Dr Eduardo e Brizano desceram rapidamente da viatura e efetuaram a abordagem do indivíduo identificado como ALAN HENRIQUE FERREIRA AGUIAR; que, efetuada revista no mesmo encontrada no bolso de sua bermuda a quantia de RS44,00 em moeda corrente fracionada; que, o depoente e Stringhetta foram até o local onde o indivíduo estava guardando o entorpecente, cerca de dez metros da abordagem e vieram a encontrar 24 eppendorfs de Cocaina e 14 porções de Maconha, fracionados, prontos para serem comercializados; que, o depoente não conhecia o indiciado." Não foi ouvido em juízo.

ALAN HENRIQUE FERREIRA AGUIAR, em declarações perante a autoridade policial, disse que "é usuário de crack e está praticando a traficancia para sustentar seu vício para não precisar roubar; que, sua mãe está ciente de sua prisão através do telefone 19-9(...)88, sendo que não possui advogado constituído dispensando a presença deste profissional; que, não sofreu qualquer tipo de agressão ou coação, e

passou por exame de corpo de delito junto ao PS local; que, já tem passagens anteriores por roubo, furto e tráfico de drogas; que, não conhece os policiais civis que o prenderam nesta tarde; que, é usuário de crack há dois anos e por conta disso mora na rua, não tendo residência fixa; que, as drogas que foram localizadas lhe pertencem e estava vendendo; que, afirma que pela venda de drogas as vezes ganha dinheiro e as vezes ganha crack como forma de pagamento; que, o interrogando quando de sua prisão foi informado de seus direitos constitucionais, de permanecer calado, de avisar seu familiares de sua prisão, de constituir advogado, dentre outros." Em juízo declarou-se culpado. Reiterou que vendia drogas para sustentar seu vício. Está em situação de rua e por isso muda de cidade. Usa drogas desde os 13 anos, começando pela cocaína. Usa o crack hoje por ser mais forte.

Independentemente de o acusado ter confessado os fatos, o depoimento da testemunha foi uniforme e coerente, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo (notadamente as filmagens captadas pela polícia civil), atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado

em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...) Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena

base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. A pessoa acusada possui maus antecedentes (autos 0000473-65.2016.8.26.0538), razão pela qual fixo a pena em seis anos e seis meses de reclusão, além de 650 dias-multa.

4. As condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes.

Precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem.

6. Evidenciado que o paciente ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, aptas a justificar a majoração da reprimenda na primeira e na segunda fases da dosimetria, não há que se falar em bis in idem.

STJ, HC 528.733/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019.

Segunda etapa. Presente a agravante da multirreincidência (certidão de antecedentes de fls. 68/72, autos 0000552-48.2020.8.26.0653 e 1501544-03.2018.8.26.0653), pela qual aumento a pena 1/3 (um terço), resultando em oito anos e oito meses de

reclusão e 866 dias-multa.

Deixo de valorar a confissão, pois nada acrescentou ao decreto condenatório, sendo restrita ao que ficou evidente pelo flagrante e pelas filmagens.

A confissão "espontânea" que, segundo alegam os apelantes, deveria ser causa de atenuação das penas, em verdade, não justifica a medida benéfica. Isso porque, como se vê mesmo a um exame perfunctório, limitaram-se a admitir o óbvio, já que foram presos em flagrante delito de roubo majorado tentado, enquanto tentavam roubar um banco. Surpreendidos pela polícia, fizeram reféns clientes e funcionários da agência, empreendendo fuga e trocando tiros com a polícia.

Seria ilógico premiá-los apenas por não terem utilizado o direito que o ordenamento lhes garante de mentir descaradamente.

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002029-19.2013.8.26.0244, 16ª Câmara Criminal, rel.

Desembargador Otávio de Almeida Toledo, julgado em 16 de dezembro de 2014.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Súmula 545 do STJ.

Terceira etapa. Na hipótese dos autos, incide a causa de aumento do inciso III do art. 40 por conta da proximidade do local onde a droga estava com os estabelecimentos de ensino e saúde (fls. 124/126 - EMEF Ruth Barroso Teixeira e Creche Prof. Silvia Melo Marques Ribeiro e da unidade de saúde UBS Antônio Gallo) e por inexistirem elementos a neutralizar os efeitos desta proximidade sobre a exposição do bem jurídico tutelado pela norma penal. Majoração em 1/6 (um sexto).

Sendo o réu reincidente e em razão do montante de pena, o regime é, necessariamente, o fechado. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial fechado. A reincidência também impede a aplicação do redutor, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional. Neste sentido:

A agravante obsta o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, juntamente com a pena corporal, obrigava a fixação do regime inicial fechado e impedia a substituição por restritivas de direitos.

TJSP, Apelação n. 0000411-36.2016.8.26.0599, Rel. Des. Vico Manhães, j. 23.05.2018.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR ALAN HENRIQUE FERREIRA AGUIAR à pena de reclusão, pelo prazo de dez anos, um mês e 10 dias, em regime inicial fechado, bem como a 1213 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado.

4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas).

5. Ordem denegada.

STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 23 de março de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA